DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE : EXP. NRO. 10-2022-DTD-CECARD/ARBITRAJE DE EMERGENCIA/ AYA.

MODALIDAD DE ARBITRAJE : Arbitraje de Emergencia.

PARTES INTERVINIENTES :

Demandante : Consorcio León

Demandado : Municipalidad Provincial de Quiñota – Cusco

ARBITRO DE EMERGENCIA : Abg. Daniel Triveño Daza.

SECRETARIA ARBITRAL : Abg. Rosnery Gladis Domínguez Quispe.

PEDIDO CAUTELAR : Medida Cautelar de No Innovar

INICIO DE LA SOLICITUD : 08 de Julio de 2022.

FECHA DE CONCLUSION : 25 de Julio de 2022.

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

CENTRO DE ARBITRAJE
CECARD
RECIBIDO
25 JUL 2022
Nº de Registro 065 Nº de Folios 23
Hora 4:26 p.m. Firma
LA RECEPCIÓN NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

CONSORCIO LEÓN vs. MUNICIPALIDA DISTRITAL DE QUIÑOTA

DECISIÓN N° 5 – CUADERNO CAUTELAR

Lima, 25 de julio de 2022

ANTECEDENTES:

i) El escrito presentado por el Consorcio León (en adelante, Consorcio) el 08 de julio 2022, bajo la sumilla: *"Solicitamos se dicte medida cautelar."*

ii) El escrito presentado por el Consorcio el 14 de julio de 2022, bajo la sumilla: "Remito informe técnico de estado situacional".

ANÁLISIS:

1. Mediante Decisión N° 3, entre otros, se suspendió el plazo para emitir la decisión que resuelve el pedido cautelar hasta que el Consorcio cumpla con acreditar los honorarios arbitrales.

2. En ese sentido, verificado el árbitro de emergencia que, el Contratista ha cumplido con acreditar los pagos correspondientes, dispone levantar la suspensión para emitir la decisión que resuelve el pedido cautelar.

3. Mediante la Decisión N° 1, entre otros, se corrió traslado a la Municipalidad Distrital de Quiñota (en adelante, la Entidad) del pedido cautelar de no innovar solicitado por el Consorcio para que en un plazo de dos (2) días hábiles, exprese lo conveniente a su derecho. Asimismo, se precisó que vencido dicho plazo, con o sin absolución de parte de la Entidad, este Árbitro resolvería la medida cautelar.

4. En ese sentido, pese al tiempo transcurrido la Entidad no cumplió con absolver el traslado conferido, lo que corresponde dejar constancia.

5. Por lo que, este Árbitro de emergencia considera proceder a resolver el pedido cautelar de no innovar presentado por el Consorcio.

6. En efecto, mediante el escrito de antecedentes **(i)**, el Consorcio solicitó se le otorgue una **medida cautelar de no innovar,** a fin de que se:

   "Que, en tanto no se haya emitido laudo definitivo, el Tribunal ordene o disponga que la Entidad se abstenga y/o suspensa la ejecución, bajo cualquier concepto, de las siguientes cartas fianza, así como sus respectivas renovaciones, emitidas a favor de la Entidad en el marco del Contrato N°090-2019-MDQ, contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y

Saneamiento en los Sectores de Miraflores, Ututa, Trankapunco, Tutoroqo, Iquiyancha, Mamach'ucclla, Ccollapacc'aza, Lluscc'ojom Mamanchisniyoc y Janccayo en la Comunidad de Ccollana Distritp de Quiñota, Provincia de Chumbivilcas – Cusco" con código 345110, relativo a la Licitación Pública N° 003-2019-MDQ-1:

a) CARTA FIANZA N° E1879-08-2020, emitida por SECREX CESCE, hasta por el monto de S/ 95,661.56 (Noventa y cinco mil seiscientos sesenta y uno con 56/100 soles) y sus respectivas renovaciones, por concepto de garantía de adelanto de materiales.

b) CARTA FIANZA N° E2740-07-2019, emitida por SECREX CESCE, hasta por el monto de S/ 434,825.30 (Cuatrocientos treinta y cuatro mil ochocientos veinticinco con 30/100 soles) y sus respectivas renovaciones, por concepto de garantía de fiel cumplimiento.

c) CARTA FIANZA N° E1760-03-2021, emitida por SECREX CESCE, hasta por el monto de S/ 29,085.55 (Veintinueve mil ochenta y cinco con 55/100 soles) y sus respectivas renovaciones, por concepto de garantía de fiel cumplimiento.

d) CARTA FIANZA N° E1759-03-2021, emitida por SECREX CESCE, hasta por el monto de S/ 35,921.18 (Treinta y cinco mil novecientos veintiuno con 18/100 soles) y sus respectivas renovaciones, por concepto de garantía de fiel cumplimiento."

7. Asimismo, el Consorcio, solicitó que, una vez concedida la medida cautelar, se proceda a oficiar a Secrex Cesce, en calidad de entidad emisora de las Carta Fianza señaladas, a fin de que tome conocimiento de la decisión cautelar.

8. Ahora bien, el Consorcio, sustenta su posición en base a la siguiente argumentación:

(i) El Consorcio, en cuanto a la **verosimilitud del derecho invocado**, señala que la pretensión a plantear en el cuaderno principal, será la siguiente:

- ***PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL***

  "Que se declare la invalidez y/o ineficacia de la resolución del Contrato N° 90-2019-MDQ, contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en los Sectores de Miraflores, Ututa, Trankapunco, Tutoroqo, Iquiyancha, Mamach´ucclla, Ccollpacb c´aza, Lluscc´ojom Mamanchisniyoc y Janccoyo en la Comunidad de Ccollana Distrito de Quiñota, Provincia de Chumbivilcas – Cusco", efectuado por la Entidad mediante Resolución de Alcaldía N° 432-2021-MDQ, por la causal "acumulación de penalidad máxima", notificado mediante Carta Notarial el 18 de abril de 2022.

- ✓ Asimismo, el Consorcio señala que existe una alta probabilidad de certeza que su pretensión sea amparada, pues considera que la Entidad no ha cumplido con realizar un adecuado cálculo de aplicación de penalidades, ya que solo se limitó a indicar en el acto administrativo que resuelve el Contrato (Resolución de Alcaldía N° 432-2021-MDQ) que el Consorcio habría acumulado la penalidad máxima, omitiéndose realizar el cálculo y el reemplazo de la fórmula prevista en el artículo 162 del Reglamento, para poder configurarse la causal establecida para la resolución del contrato.

- ✓ En ese mismo sentido, el Consorcio señala que se debe considerar que el informe del cálculo de penalidades debe contener la motivación necesaria que permita establecer cómo es que se determina el monto ascendente a la penalidad, señala que en el Informe N° 141-2021-YALS-AC-OSLO/MDQ-CH se aprecia que los datos considerados para el cálculo de penalidad, son inexactos y no se justifican las razones por las que se consideran las variables aplicables a la fórmula.

- ✓ Del mismo modo, el Consorcio señala que se debe considerar que el documento no fue expedido por un funcionario de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras ni por el órgano de administración de la Entidad, quienes cuentan con la información exacta que le permitan otorgar los valores reales para su reemplazo en la formula.

- ✓ En atención a lo señalado, el Consorcio manifiesta que acreditará en el cuaderno principal de manera objetiva que los retrasos no le son imputables, por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 162.5 del art. 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se le deberá eximir de la aplicación de la penalidad por mora.

- ✓ Asimismo, el Consorcio indica que la Entidad omitió cumplir con la condición establecida en el art. 207 del Reglamento, mediante la cual se exige que, en los contratos de resolución del contrato de obras, es necesario que en el documento donde se decide resolver el contrato, debe indicarse fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no menor de tres (03) días hábiles. Sobre el particular, el Consorcio manifiesta que la Resolución de Alcaldía N° 432-2021- MDQ no cumple con este requisito y el procedimiento previsto en la normativa de las contrataciones del Estado, por lo que, considera que la comunicación realizada en la Carta Notarial el 18 de abril de 2022, es nula.

- ✓ Adicionalmente, el Consorcio señala que para determinarse la validez o no de la resolución del contrato de obra efectuada por la Entidad se debe identificar si en dicho acto se han cumplido las formalidades relativas a la

resolución del contrato y si las causales invocadas por la Entidad son válidas y/o están reguladas en la normativa de contrataciones con el Estado.

- ✓ En ese sentido, el Consorcio manifiesta que respecto al procedimiento para la resolución del contrato, el Tribunal de Contrataciones, en el numeral 1 del Acuerdo de Sala Plena del 6/2012 del 20 de septiembre de 2012, se pronunció respecto a la inobservancia del procedimiento referido a la resolución contractual; indicando que la inobservancia del procedimiento de resolución contractual implica la exención de responsabilidad del contratista, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa de los funcionarios y/o servidores responsables. En ese sentido, el Consorcio señala que no podría validarse una resolución de contrato efectuado sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

- ✓ Asimismo, el Consorcio manifiesta que cumplió con objetar la resolución de contrato en su oportunidad, activando su derecho a solicitar el inicio del procedimiento de conciliación para resolver la controversia. En tal sentido, la resolución del contrato efectuado por la Entidad no se encuentra consentida. Sin embargo, la Entidad pretende ejecutar las cartas fianzas otorgadas como garantías.

- ✓ Respecto a la ejecución de garantías, el Consorcio señala que el artículo 131° del reglamento regula lo siguiente:

  Artículo 131.- Ejecución de garantías
  Las garantías se ejecutan en los siguientes supuestos:

  (…)
  2. La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

  (…)

  4. La garantía por adelantos se ejecuta cuando resuelto o declarado nulo el contrato exista riesgo sustentado de imposibilidad de amortización o pago, aun cuando este evento haya sido sometido a un medio de solución de controversias.

En cualquiera de los supuestos contemplados en el párrafo anterior, la Entidad en forma previa a la ejecución de la garantía por adelantos, requiere notarialmente al contratista, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para que devuelva el monto pendiente de amortizar, bajo apercibimiento de ejecutar la garantía por adelantos por dicho monto (resaltado es agregado)

- ✓ Sobre el particular, el Consorcio manifiesta que la garantía de fiel cumplimiento se puede ejecutar siempre y cuando la resolución del contrato se deba a causas imputables al Contratista y que, además, ésta se encuentre consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. Señala que, para el presente caso, conforme puede apreciarse en las copias de las cartas fianzas adjuntas a su solicitud, las cartas se encuentran vigentes, por lo que, no existe motivo que justifique su ejecución.

- ✓ Asimismo, el Consorcio señala que se debe considerar que la ejecución de las garantías será procedente únicamente cuando la Entidad – de conformidad con lo establecido en el artículo 131 del Reglamento– luego de realizar previamente una evaluación de las circunstancias, advierta que se encuentra inmersa en uno de los supuestos habilitadores contemplados en la normativa, hecho que señala no ocurrió en el presente, toda vez que las cartas fianzas se encuentran vigentes.

- ✓ Respecto a la carta fianza otorgada como garantía de adelanto de materiales (Carta Fianza N° 1879-2020, hasta por el importe de S/ 95,661.56), el Consorcio señala que para que pueda ejecutarse, se debe requerir a dicha parte cumpla con devolver el monto pendiente amortizar, ello conforme a lo indicado en el numeral 155.2 del art. 155 del Reglamento. Asimismo, el Consorcio precisa que la referida Carta Fianza fue renovada oportunamente, a través de la Carta Fianza N° E1879-09-2020, por el mismo importe, el cual tiene vigencia hasta el 05 de octubre de 2022, lo que señala que garantiza que la Entidad pueda salvaguardar los fondos públicos involucrados con la entrega del adelanto. Con ello, señala que es evidente que la Entidad viene vulnerando el procedimiento señalado en la Ley de Contrataciones del Estado.

- ✓ En ese sentido, el Consorcio señala que mientras se encuentren vigentes las garantías otorgadas a la Entidad, ésta debe abstenerse de su ejecución, ya que la resolución del contrato no se encuentra consentida ni existe laudo arbitral que determine la validez de dicho acto.

- ✓ En ese orden de ideas, el Consorcio manifiesta que de los hechos descritos -y demostrado con los medios probatorios adjuntos a su escrito- se

demuestra la verosimilitud del derecho invocado respecto a la invalidez y/o nulidad de la resolución del contrato efectuado por la Entidad, toda vez que no se ha cumplido con las formalidades previstas en la normativa de las contrataciones del Estado, evidenciándose prima facie, que se han cumplido todos los requisitos legales para la procedencia de su pretensión.

(ii) Ahora bien, en cuanto al **peligro de la demora**, el Consorcio señala que este se configura en la medida que, al haberse verificado graves errores cometidos por la Entidad en el procedimiento de resolución de contrato, por lo que considera que la misma debe ser declarada nula. No obstante, el Contratista expone que la ejecución de las cartas fianzas que fueron solicitadas por la Entidad.

Asimismo, el Consorcio señala que la medida cautelar presentada cabe en impostergable debido al peligro que representa, puesto que la ejecución de la carta fianza traerá consigo perjuicios irreparables para los integrantes de Consorcio, dado que todas las entidades financieras negarán la emisión de fianzas lo que derivará en la imposibilidad de seguir contratando con el Estado, y en general convirtiéndonos en parias del sistema financiero.

Aunado a lo expuesto, el Consorcio señala que esta medida es impostergable puesto que resultaría desalentador para todo contratista suscribir contratos con el Estado, pues no se contaría con mecanismos efectivos y rápidos para postergar decisiones irrazonables.

(iii) En relación a la **adecuación de la medida cautelar**, el Consorcio señala que esta debe ser idónea para poder garantizar la eficacia del laudo que ampare determinada pretensión. La relación entre medida cautelar y pretensión es de idoneidad y proporcionalidad, y a ello se refiere la razonabilidad como presupuesto de las medidas cautelares.

(iv) En lo que respecta a la **necesidad**, el Consorcio señala que es claro que la medida cautelar solicitada es idónea para garantizar la efectividad de la tutela del derecho del Contratista, pues es la única medida legal que podría evitar cualquier acto arbitrario -ejecución de cartas fianza, resolución del Contrato, aplicación de penalidades con riesgo a alcanzar el límite permisible legalmente o intervención económica- que modifique la actual situación de hecho o de derecho (statu quo) en perjuicio del Contratista.

(v) Respecto a la reversión de los efectos de la decisión, el Consorcio señala que es preciso indicar que la medida solicitada será otorgada bajo cuenta y riesgo del Consorcio garantizando un posible daño con la contracautela a entregar.

(i) En relación a la **contracautela**, el Consorcio manifiesta que, de acuerdo a la naturaleza de la medida solicitada y al monto de la misma, ofrece como contracautela la correspondiente caución juratoria por la suma de S/. 1'000,000.00 (Un millón con 00/100 soles).

9. Ahora bien, este Árbitro de emergencia considera pertinente establecer el marco legal sobre el cual se analizará la procedencia de la medida cautelar dentro del ámbito del proceso arbitral, a fin de poder resolver la solicitud cautelar de no innovar.

10. Al respecto, la medida cautelar es un pronunciamiento de carácter temporal que obliga a hacer o no hacer algo con la finalidad de proteger el resultado de una litis, pues debido a la demora en la resolución del conflicto, puede ocasionarse la pérdida o deterioro del derecho reclamado, con lo cual la ejecución de un eventual resultado favorable podría verse menoscabado con la pérdida de tal derecho.

11. Alberto Hinostroza señala que la medida cautelar es aquella institución procesal, mediante la cual el órgano jurisdiccional, a instancia de parte, asegura la eficacia o el cumplimiento de la sentencia a dictarse en el proceso que dirige, anticipando todos o determinados efectos del fallo[1]. De igual modo, para Monroy *"(…) el periculum in mora es la constatación que hace el Juez, que si no concede la medida cautelar, puede que el fallo definitivo llegue a ser ilusorio o inejecutable. En tal sentido, debe haber una amenaza que ponga en riesgo la efectividad del fallo"*[2]

12. Asimismo, el Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, en su artículo 47° regula las medidas cautelares como:

> *"**Artículo 47°.- Medidas Cautelares:***
> *(…) 2. Por medida cautelar se entenderá toda medida temporal, contenida en una decisión que tenga o no forma de laudo, por la que, en cualquier momento previo a la emisión del laudo que resuelve definitivamente la controversia, el tribunal ordena a una de las partes:*
>
> *a. Que mantenga o restablezca el status quo en espera de que se resuelva la controversia;*
> *b. Que adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente o el menoscabo del proceso arbitral, o que se abstenga de llevar a cabo ciertos*

[1] HINOSTROZA MINGUÉZ, Alberto. El embargo y otras medidas cautelares. Editorial San Marcos, 2da edición. Lima, 2000. Pág. 13.

[2] Citado por SIMONS, Adrián. Medidas cautelares especiales y poder general de cautela. En: Revista Advocatus. Universidad de Lima. Nº 7. Diciembre de 2002. Pág. 161.

actos que probablemente ocasionarían dicho daño o menoscabo al proceso arbitral;

c. Que proporcione algún medio para preservar bienes que permitan ejecutar el laudo subsiguiente; o

d. Que preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes y pertinentes para resolver la controversia." (Lo resaltado es agregado).

13. En ese contexto, es de apreciar que la Ley de Arbitraje establece claramente que en sede arbitral se pueden dictar medidas cautelares, otorgando a los árbitros las facultades para conceder o no las mismas.

14. No cabe duda que, el Árbitro de emergencia cuenta con las facultades necesarias para dictar medidas cautelares conforme al dispositivo legal anteriormente citado, por lo que, en virtud de ello, este Árbitro cuenta con competencia para emitir el pronunciamiento respectivo.

15. Por otro lado, es de advertir que la Ley de Arbitraje no especifica los presupuestos necesarios para el otorgamiento de una medida cautelar, por lo que es necesario recurrir a las prácticas arbitrales para poder determinar cuáles son dichos presupuestos, y a la luz de los mismos, analizar si el pedido de medida cautelar de no innovar presentado por el Contratista cumple con ellos o no.

16. Al respecto, en el ámbito internacional se reconoce como presupuestos para conceder una medida cautelar lo siguientes: i) se tenga la certeza del derecho o "fumus bonis iure"; ii) que exista un peligro de daño sobre el derecho reclamado por la demora, iii) que exista una adecuación o razonabilidad de la medida cautelar, y; iv) que se ofrezca una contracautela que garantice los posibles daños que pudiera ocasionar a la contraparte con el otorgamiento de la medida cautelar[3].

17. Asimismo, el Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente al presente proceso, establece lo siguiente:

"Artículo 611.- Contenido de la decisión cautelar
El juez, atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal y a fin de lograr la eficacia de la decisión definitiva, dicta medida cautelar en la forma solicitada o en la que considere adecuada, siempre que, de lo expuesto y la prueba presentada por el demandante, aprecie:
1.- La verosimilitud del derecho invocado.
2.- La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro la demora del proceso o por cualquier otra razón justificable.

[3] BERGER, K.P. International economic arbitration. Kluwer. Deventer: 1993 Págs. 331-351.

3.- La razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión. (…)".

18. En ese sentido, este Árbitro concluye que, de acuerdo con las prácticas arbitrales tanto internacionales como nacionales y a lo establecido en el Art. 611 del CPC, los requisitos para solicitar una medida cautelar son: i) la verosimilitud del derecho; ii) peligro en la demora, iii) adecuación de la medida cautelar o razonabilidad de la medida cautelar y; iv) la contracautela.

19. Sobre los presupuestos de la medida cautelar, la verosimilitud del derecho invocado por el juez peruano Marte Chang señala lo siguiente; *"la realización de un juicio de probabilidad, provisional e indiciario a favor del accionante, no exige comprobación de certeza, sino solamente de humo de derecho, esto es, de probabilidad".*[4]

20. En ese sentido, la verosimilitud del derecho invocado no supone un convencimiento total o cierto del juzgador respecto a las alegaciones, sino solo una apariencia de verdadero (fumus iuris boni), una hipótesis razonable que no se puede considerar prima facie como un pedido ajeno a derecho y que estará sujeta a un examen y decisión posterior que podría inclusive ser al momento de la emisión del laudo.

21. Por otro lado, respecto al peligro en la demora la doctrina a través del autor Ezequiel Cassagne nos menciona que:

> *"Es el peligro en la demora de la sentencia definitiva que se dictará en el proceso, o como dicen GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, "la urgencia para evitar que la demora en la resolución del pleito principal cause perjuicios apreciables" Se requiere que sobrevenga un perjuicio o daño inminente que transformará en tardío el eventual reconocimiento del derecho invocado como fundamento de la pretensión"*[5].

22. Por su parte el doctor Enrique Palacios Pareja, nos menciona que:

> *"Ahora bien, el derecho no solo tiene que encontrarse en una situación de riesgo, es imprescindible que dicho riesgo radique en la demora que el proceso supone, ya que de otra forma la medida cautelar no será el medio idóneo para reducir dicho riesgo. Por ejemplo, el embargo para evitar que durante el transcurso del proceso el deudor demandado disponga de su patrimonio haciendo ilusorio el derecho de*

---

[4] MARTEL CHANG, Rolando A. *Tutela Cautelar y medidas autosatisfactivas en el proceso civil.* Lima, Palestra Editores, 2003, p. 59

[5] Cassagne, E. *"Medidas cautelares contra la administración".* Pág. 11 Recuperado el 17 de abril de 2018 de:http://www.cassagne.com.ar/publicaciones/Las_medidas_cautelares_contra_la_Administracion,_en_Tratado_de_Derecho_Procesal_Adminsitrativo,_Director_Juan_Carlos_Cassagne,.pdf

crédito del acreedor demandante; o la suspensión de los efectos de una resolución administrativa impugnada judicialmente, que dispuso la clausura de un negocio, evitando así que mientras dure el proceso judicial se mantenga cerrado el negocio, con los graves perjuicios que ello ocasiona"[6].

23. En ese sentido, la configuración del ***periculum in mora*** se produce cuando de la constatación razonable de los hechos se evidencia que si el juzgador no concede la medida cautelar solicitada en el momento pedido, no podrá hacerlo en el futuro, debido a que por la demora en el proceso el daño podría convertirse en irreparable o; que el fundado temor en la espera de la tutela efectiva, lleguen a fallar o alterar las circunstancias de hecho favorables a la tutela misma.

24. De ahí que, el peligro en la demora debe ser apreciado con relación a la urgencia en obtener protección especial, dado los hechos indicativos de la irreparabilidad o el grave daño que puede significar esperar al dictado de sentencia, buscándose con este tipo de pedidos garantizar los efectos del ulterior fallo sino cautelar el ***statu quo*** hasta el fallo definitivo.

25. Por otro lado, respecto a la **adecuación o razonabilidad** de la medida cautelar, Jorge Antonio Plasencia Cruz[7] señala que el presupuesto de adecuación exige que el Juez deba ponderar la medida cautelar solicitada a aquello que se pretende asegurar, debiendo dictar la medida que de menor modo afecte a los bienes o derechos de la parte demandada o, en todo caso, dictar la medida que resulte proporcional con el fin que se persigue.

26. En ese sentido, debe señalarse que la medida cautelar debe ser proporcionada y evitar causar perjuicio a la contraparte.

27. Finalmente, la **contracautela**, como expresa el doctor Mariano Peláez Bardales[8], nos menciona que:

"Ronal Arazi, en su obra Medidas Cautelares, refiere respecto de la contracautela que esta ***se funda en el principio de igualdad, en razón de que persigue el***

---

[6] Palacios Pareja, E. (s.f.). Reflexiones sobre la caducidad de las medidas cautelares. En *Revista Ius Et Veritas 29* (págs. 23-31). Lima. Recuperado el 17 de abril de 2018 de: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSjoeou8LaAhXC3VMKHS4IACoQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Frevistas.pucp.edu.pe%2Findex.php%2Fiusetveritas%2Farticle%2Fdownload%2F11531%2F12051&usg=AOvVaw1nSpsdmR7IVkPw2YmDRiBg

[7] Plascencia Cruz, Jorge. La Buena Fe en el Proceso Cautelar; Derecho y Cambio Social. https://www.derechoycambiosocial.com/revista013/buena%20fe%20en%20el%20proceso%20cautelar.htm

[8] Peláez Bardales, M. (s.f.). *El Proceso Cautelar 2° Edicion.* Lima: Grijley. Pág. 44

equilibro entre las partes*; por un lado, se autoriza al peticionario a asegurar un derecho aún no reconocido judicialmente, pero por otro se garantiza a éste la efectividad del resarcimiento por los daños y perjuicios que pudiere ocasionarle, si aquel derecho no existiera. (…)*

(…) ***La contracautela se funda en el principio de igualdad y reemplaza en cierta medida a la bilateralidad o controversia asegurando al demandado frente al actor con una pretensión discutida o insatisfecha, la posibilidad de resarcirse los daños si esa pretensión no existiera o no llegare a actualizarse****, es, para quien pide la medida cautelar, una seguridad en caso de habérsela solicito mal".* (El resaltado y subrayado es nuestro).

28. Ante ello, este Árbitro de emergencia considera que si bien la tutela cautelar busca proteger al accionante en aquel posible futuro derecho que le asista y que se demuestre en el proceso principal, lo cierto es que también es importante no dejar desprotegido al demandado, en este caso la Entidad, debiendo tomarse todas las precauciones a fin de que pueda ser indemnizado por los posibles daños que genere la admisión de una medida cautelar de esta naturaleza.

29. En ese sentido, lo que corresponde verificar es si esta solicitud cumple con los presupuestos señalados anteriormente.

RESPECTO DE LA VEROSIMILITUD DEL DERECHO INVOCADO:

30. En primer lugar, se debe verificar si existe una apariencia del derecho conforme ha argumentado el Consorcio, por regla general la comprobación o prueba plena de la existencia de un derecho no solamente requiere de la instrucción suficientemente extensa para formar convicción –certeza– al árbitro, sino que exige el contradictorio, es decir, la asistencia o posibilidad de hacerlo de ambos sujetos con interés en el litigio.

31. En las medidas cautelares, conforme al interés que las justifica: el temor de la frustración o su urgencia, exigen suprimir o disminuir la instrucción y demorar la partición de uno de los interesados hasta que se hayan cumplido. De allí que la comprobación de la existencia del derecho se haga en forma sumaria –cognición sumaria–, de manera que proporcione la verosimilitud de derecho[9]. Por eso, la adopción de la medida cautelar no debe depender de que el actor pruebe la existencia del derecho subjetivo por él alegado en el proceso principal, ya que esa existencia es la que se debate en éste, pero tampoco puede adoptarse la medida cautelar sólo porque lo pida el actor, en uno y otro extremo la adopción precisa que se acrediten unos indicios de probabilidad, verosimilitud de apariencia del buen derecho[10] . Al respecto, el autor PODETTI refiere «El interés privado

[9] PODETTI, J. Ramiro. Tratado de las Medidas Cautelares. Tomo IV, Editorial Ediar, Buenos Aires 1956, p. 54
[10] BARONA VILAR, Silvia. Derecho Jurisdiccional II: proceso civil. Tirant Lo Blanch, Valencia 2008, p. 680

y público de asegurar la oportuna y eficaz actuación de un derecho, permite prescindir, provisionalmente, de su justificación, pero nunca de su existencia»[11]. Por eso, al ser el procedimiento cautelar sumario, sin la existencia de estación probatoria, menos la posibilidad de su actuación nace el presupuesto de verosimilitud del derecho. De allí que el profesor JUAN JOSÉ MONROY GÁLVEZ manifieste que precisamente, por aquella situación de urgencia, el actor tan sólo se limita a presentar una información sumaria respecto de las posibilidades de su posición frente al proceso[12.] Precisa, la razón de ser de la verosimilitud, llamado fumus boni iuris, es que requiere para la obtención de la medida cautelar sólo el "humo" de la existencia del derecho que solicita el demandante[13] .

32. La medida cautelar se concede al demandante o actor no porque ostente un derecho indiscutido y pleno sobre el objeto del proceso, sino, porque simplemente prima facie, es decir, preliminarmente su pretensión o derecho invocado parece amparable, situación que debe acreditarse con una prueba documental. No debe el juez perseguir la certeza, porque ella es el producto de una secuencia activa de verificaciones y deducciones lógicas que juegan armónicamente en un momento diferente del juicio. Al órgano jurisdiccional le basta y es suficiente la apariencia fundada del derecho, lo que equivale a responder asertivamente a la viabilidad jurídica de la pretensión, pero sin que ello signifique adelantar opinión alguna sobre el fondo del problema[14] . KIELMANOVICH destaca que algunos casos la ley presume la verosimilitud del derecho, por las situaciones de las personas, la naturaleza de la pretensión o por el estado del proceso en el cual se pide, así cuando se trata de medidas cautelares a favor de quien obtuvo sentencia favorable[15] .

33. Atendiendo a lo expuesto, se debe verificar si existe una apariencia del derecho conforme ha argumentado el Consorcio. Sobre este punto, este árbitro puede advertir que la pretensión que el Consorcio solicitará en el proceso arbitral es la siguiente:

- *Que se declare la invalidez y/o ineficacia de la resolución del Contrato N° 90-2019-MDQ, contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en los Sectores de Miraflores, Ututa, Trankapunco, Tutoroqo, Iquiyancha, Mamach´ucclla, Ccollpacb c´aza, Lluscc´ojom Mamanchisniyoc y Janccoyo en la Comunidad de Ccollana Distrito de Quiñota, Provincia de Chumbivilcas – Cusco", efectuado por la Entidad mediante Resolución de Alcaldía N° 432-2021-*

[11] PODETTI, J. Ramiro. Tratado de las Medidas Cautelares. Tomo IV, ob. Cit., p. 55-56.
[12] MONROY PALACIOS, Juan José. Bases para la formación de una Teoría Cautelar. Editorial Chavín, Comunidad, Lima 2002, p. 171.
[13] MONROY PALACIOS, Juan José. Bases para la formación de una Teoría Cautelar. Ob. Cit., p. 173-174
[14] HINOSTROZA, Alberto. El Embargo y Otras Medidas Cautelares. Editorial San Marcos, Lima 2002, p. 38.
[15] KIELMMANOVICK, Jorge. Medidas Cautelares. Editorial Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires 2000, p. 52.

MDQ, por la causal" acumulación de penalidad máxima notificado mediante Carta Notarial el 18 de abril de 2022.

34. Mediante dicha pretensión, se advierte que el Consorcio busca que se declare la invalidez y/o ineficacia de la Resolución de Alcaldía N° 432-2021-MDQ, a través de la cual la Entidad resolvió el contrato, conforme ha sido desarrollado en su escrito de solicitud cautelar. En primer lugar, debido a que considera que la resolución de contrato no se encuentra motivada, en el sentido que no se ha dispuesto las razones y el cálculo de la penalidad por mora y en segundo lugar, considera que no se ha cumplido con el procedimiento respectivo que establece el Art. 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el sentido que no se indicó fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario del lugar de la obra.

35. Respecto a la motivación de la aplicación de las penalidades, debe señalarse que todos los actos emitidos por las Entidades públicas, deben estar debidamente motivados para adquirir validez, tal como lo ha señalado el Art. 3 del TUO de la Ley 27444[16]. En ese sentido, si los hechos que señala el Contratista resultan ciertos existe la posibilidad de que su pretensión sea amparada en el proceso principal.

36. Asimismo, respecto de la omisión de la indicación de fecha y hora para la constatación física, se debe tener en cuenta que las Entidades estan obligadas a cumplir con el procedimiento de resolución contractual establecido en la Ley de Contrataciones y su reglamento, a fin de esta sea declarada valida y eficaz. Ello ha sido incluso manteria de pronunciamiento por parte del Tribunal de Contrataciones mediante Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 20 de septiembre de 2012[17].

37. En atención a ello, de verificarse en el cuaderno principal alguna de las razones alegadas en este cuaderno por el Contratista, la resolución contractual efectuada a través de la Resolución de Alcaldía N° 432-2021-MDQ devendría en invalida e ineficaz, por lo que, no existiría motivo legal, salvo que no se renueve las cartas fianzas, para ejecutar las Cartas Fianzas emtida por el Contratista.

---

[16] *Art. 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos:*
(…)
*4. **Motivación. -** El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.*

[17] *"(…)*
En los casos de resolución de contratos, las Entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento de resolución contractual (…). La inobservancia del mencionado procedimiento por parte de la Entidad, implica la exención de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa de los funcionarios y/o servidores responsables. (…)"

38. En ese orden de ideas, queda acreditado que existe verosimilud del derecho en el pedido del contratista, pues guardan vinculación directa su pedido principal con las Cartas Fianzas que pretende salvaguardar.

RESPECTO AL PELIGRO EN LA DEMORA

39. Respecto al requisito del peligro en la demora, éste es un presupuesto objetivo de la medida cautelar, el cual no sólo se constituye por la existencia de un peligro, sino que además es indispensable que dicho peligro sea inminente, por lo que, resulta necesario e imprescindible expedir un remedio inmediato y eficaz, en tanto se tramita el proceso principal.

40. En efecto, Ottolengui, citado por Monroy Gálvez[18] en su obra "Temas de Proceso Civil" señala al respecto que "*Para aproximarse a una noción más clara del periculum in mora, no basta solamente que el interés de obrar nazca de un estado de peligro y que la medida solicitada tenga por ello la finalidad de prevenir un daño temido, sino que por el contrario es necesario que, a causa de esta inminencia de peligro, tal medida tenga carácter de urgencia, en cuanto sea de prever que, si la misma se demorase, se transformaría en daño efectivo o se agravaría el ya ocurrido; esto es, que la providencia cautelar debe ser dictada sin demora, de otro lado sería ineficaz".* Montero Rosas, haciendo referencia a Fairen Guillen afirma que "*el periculum in mora básico de las medidas cautelares, no es el peligro de daño genérico jurídico, al cual se atiende mediante los dos procesos clásico, sino el peligro específico derivado de la duración de la actividad jurisdiccional, considerada en sí misma como posible causa de un ulterior daño; mientras que el daño ya causado encuentra su remedio en los procesos declarativo y ejecutivo, las medidas cautelares tratan de evitar que ese daño se agrave como consecuencia de la duración de aquellos.*[19]

41. Así pues, este elemento significa que la medida cautelar sólo se justifica cuando tiene por propósito evitar un daño grave al derecho invocado por el solicitante de la medida

[18] MONROY GÁLVEZ, Juan. Tema de Proceso Civil. Ediciones Studium. Lima. Pág. 28.

[19] MONTERO AROCA, Juan. Trabajos de derecho procesal. Ed. Bosch. Barcelona, 1998. Pág. 608.

cautelar y, en este caso, se debe tener en cuenta el artículo 155[20] del Reglamento de Contrataciones con el Estado[21], el mismo que establece lo siguiente:

"Artículo 155. Ejecución de garantías
155.1 Las garantías se ejecutan en los siguientes supuestos:
a) ***Cuando el contratista no la hubiere renovado*** *antes de la fecha de su vencimiento.*
(…)
b) ***La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta****, en su totalidad,* ***cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato.*** *En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.*
c) Igualmente, ***la garantía de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres (3) días hábiles de haber sido requerido por la Entidad****, el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta de conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, o en la liquidación final del contrato, en el caso de consultoría de obras y ejecución de obras.*
Esta ejecución es solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del contratista.
d) ***La garantía por adelantos se ejecuta cuando resuelto o declarado nulo el contrato, no se realice la amortización o el pago****, aun cuando este evento haya sido sometido a un medio de solución de controversias.*
155.2. En cualquiera de los supuestos contemplados en el numeral anterior, ***la Entidad en forma previa a la ejecución de la garantía por adelantos, requiere notarialmente al contratista, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para que devuelva el monto pendiente de amortizar****, bajo apercibimiento de ejecutar la garantía por adelantos por dicho monto.*
(…)"

---

[20] 1. *Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Contra esta ejecución, el contratista no tiene derecho a interponer reclamo alguno. Una vez culminado el contrato, y siempre que no existan deudas a cargo del contratista, el monto ejecutado le será devuelto a éste sin dar lugar al pago de intereses. Tratándose de las garantías por adelantos, no corresponde devolución alguna por entenderse amortizado el adelanto otorgado.*
2. La garantía de fiel cumplimiento y la garantía adicional por el monto diferencial de propuesta se ejecutarán, en su totalidad, sólo cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el contrato. El monto de las garantías corresponderá íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.
3. Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento y, de ser necesario, la garantía por el monto diferencial de propuesta, se ejecutarán cuando transcurridos tres (3) días de haber sido requerido por la Entidad, el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta de conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes y servicios, o en la liquidación final del contrato debidamente consentida o ejecutoriada, en el caso de ejecución de obras. Esta ejecución será solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del contratista.

[21] Debe recordarse que la normativa aplicable al presente es el TUO de la Ley N° 30225 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, normas vigentes al momento de la convocatoria (**17.09.2019**).

42. Tal como se puede advertir de la norma antes señala, la carta fianza de fiel cumplimiento solo se ejecutará en los siguientes supuestos:
    a) Cuando no haya sido renovada, antes de su vencimiento.
    b) Cuando exista resolución de contrato consentida.
    c) Cuando mediante laudo arbitral se haya declaro procedente la decisión de resolver.

43. Ahora bien, las cartas de adelantos se ejecutarán en los siguientes supuestos:
    a) Cuando no haya sido renovada, antes de su vencimiento.
    b) Cuando resuelto o declarado nulo el contrato, no se realice la amortización o el pago. Para este supuesto, debe existir una solicitud previa de la Entidad, a fin de que el Contratista cumpla con devolver el pago pendiente de amortizar.

44. Tal como se puede advertir ninguno de los supuestos señalados se ha configurado en el presente caso, es decir, las cartas fianzas de fiel cumplimiento han venido siendo renovadas y, la resolución del contrato no se encuentra consentida, dado que, de los medios probatorios presentados por el Contratista mediante su escrito de fecha 11 de julio de 2020, se acredita que el Consorcio inició la conciliación dentro de plazo establecido en la Ley de Contartaciones del Estado, al igual que su intención de iniciar el arbitraje. Por otro lado, sobre las cartas fianzas de adelantos debe tenerse presente que las mismas han venido siendo renovadas constantemente.

45. Asimismo, se debe precisar que no existe medio probatorio donde se verifique que la Entidad haya solicitado previamente al Contratista el pago pendiente de amortizar, más aún atendiendo a que la Entidad no absolvió el traslado conferido mediante Decisión N° 1. No obstante, pese a que no existe forma o manera legal de ejecutar las Cartas Fianzas, la Entidad mediante Carta Notarial N° 002-2022-MDQ de fecha 30 de junio de 2022, solicitó a la empresa Secrex Cesce la ejecución de las mencionadas Cartas Fianzas, conllevandose a acreditar un evidente y real peligro en la demora.

46. En atención a lo descrito previamente, el árbitro considera que se acredita el peligro en la demora en el presente caso.

<u>RESPECTO A LA ADECUACIÓN Y RAZONABILIDAD</u>

47. Respecto a la razonabilidad de la medida cautelar, en el caso que nos compete, el presente árbitro estima necesario realizar un análisis de proporcionalidad a efectos de determinar la idoneidad de la medida cautelar vinculada a la pretensión principal a ser planteada por el Consorcio.

48. Este análisis de proporcionalidad busca que toda afectación de cualquier derecho sea equilibrada y razonable, es decir, que no sea inútil ni desproporcionada. Vale indicar

que dicho análisis está fundamentado en el principio constitucional de proporcionalidad, cuyo objeto es establecer una correcta relación de preferencia (o precedencia) condicionada entre los principios o derechos en conflicto, reduciendo de los márgenes de discrecionalidad.

49. Aunado a lo anterior se debe tener en cuenta que en una medida cautelar debe haber **PROPORCIONALIDAD** entre el pedido y la situación jurídica o fáctica que es objeto de la aseguración. Así el doctor Walter Eduardo Campos Murillo indica que:

> *"(…) a fin de conceder la medida solicitada debe evaluar que el pedido cumpla con los tres requisitos, esto es que existe verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y que la medida solicitada resulte adecuada con la naturaleza de la pretensión principal, solo en este caso estará en aptitud de conceder la medida. Ocurre, sin embargo, que la ley da un tratamiento distinto al tercer requisito, pues si bien la carencia de alguno de los dos primeros requisitos determina el rechazo de la solicitud cautelar, respecto del tercero, la adecuación, la norma permite que su insuficiencia sea "subsanada" por el juez, de manera que, en definitiva, se cumpla también con ese tercer presupuesto para la concesión de la medida cautelar"*[22].

50. Adicionalmente, tal como lo señala el doctor Plasencia Cruz, Jorge Antonio[23], *"la adecuación de la medida cautelar se refiere de un lado, a la congruencia y conexidad que debe haber entre la pretensión cautelar y la pretensión principal que se quiere cautelar y, de otro, a la proporcionalidad que ha de existir entre la medida cautelar que pudiera concederse y la pretensión principal. De ese modo, se evita que se concedan medidas cautelares en exceso, sino únicamente las necesarias para cautelar de manera suficiente la pretensión principal. Es precisamente en este presupuesto que* ***la incidencia del principio de la buena fe*** *cobra especial relevancia en los sujetos partícipes del proceso, a efectos de otorgar la medida cautelar* ***"pertinente****. (el subrayado es nuestro)*

51. En ese sentido, el árbitro advierte que los derechos en conflicto en este caso son, por un lado, el derecho del Consorcio de que se declare que la invalidez y/o ineficacia de la resolución del Contrato; y por otro lado, se encuentra el derecho de la Entidad de resolver el Contrato por retrasos en la Obra, o aplicar la penalidad correspondiente por incumplimientos en la misma.

---

[22] Campos Murillo, W. *"La adecuación en las medidas cautelares"*. Recuperado el 12 de abril de: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/2eeb708043eb964c9426f40365e6754e/Adecuacion_medidas_cautelares_Walter_Eduardo_Campos_Murillo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2eeb708043eb964c9426f40365e6754e

[23] Plascencia Cruz, Jorge. La Buena Fe en el Proceso Cautelar; Derecho y Cambio Social. https://www.derechoycambiosocial.com/revista013/buena%20fe%20en%20el%20proceso%20cautelar.htm

52. En ese sentido, para evaluar la razonabilidad, congruencia y proporcionalidad, el árbitro tomará en consideración la pretensión que se discutirá en el arbitraje principal.

53. En ese orden de ideas, en el presente al evaluar la verosimilitud del derecho se ha llegado a determinar que la ejecución de las cartas fianzas guarda vinculación directa con la resolución del contrato, y determinar si esta resulta valida o no. Asimismo, en el presente caso, teniendo en consideración la pretensión planteada, no cabe duda de que la medida cautelar solicitada ostenta el requisito de adecuación antes mencionado, pues es la figura idónea para garantizar que no se produzca un perjuicio económico mayor al solicitante, siendo que este no genera ningún perjuicio desproporcionado, abusivo o innecesario a la Entidad. En tal sentido, existe razonabilidad y proporcionalidad en el pedido del Consorcio.

RESPECTO A LA CONTRACAUTELA

54. Finalmente, la contracautela opera como una garantía por la realización de la medida cautelar, fundada en el principio de igualdad pues debe preverse la posibilidad de asegurar al demandado la efectividad del resarcimiento de los daños generados por la medida cautelar[24].

55. Sin perjuicio de ello, el árbitro tiene en consideración que la contracautela consiste en una caución que presta el solicitante de la medida cautelar para garantizar el resarcimiento de cualquier perjuicio ilícito que pudiera sufrir el afectado de la medida cautelar como consecuencia de su ejecución.

56. El árbitro ha señalado que la concurrencia de: (i) la verosimilitud del derecho invocado, (ii) la existencia de peligro en la demora y (iii) la razonabilidad de la medida cautelar, se analizan para determinar si corresponde otorgar o no una medida cautelar, es decir, su procedencia; mientras que la contracautela se analiza para determinar si una medida cautelar deba ser ejecutada.

57. En la misma línea, PEYRANO señala que la prestación de la contracautela no es un requisito para su procedencia, sino solo un presupuesto para que resulte viable su ejecución.[25]

58. Ahora bien, en el presente caso se debe tener presente que el artículo 8° del Decreto de Urgencia Nro. 20-2020 *"Decreto de Urgencia que modifica el Decreto Legislativo Nº 1071",* establece que la contracautela debe estar constituida por la emisión de una carta fianza por un monto no menor a la garantía de fiel cumplimiento. Así, tenemos:

---

[24] Ledesma Narváez, Marianella. (2016) "Las Medidas Cautelares en el Proceso Civil". Pág. 33.
[25] PEYRANO, Jorge W. *Compendio de reglas procesales en lo civil y comercial*. Segunda Edición. Rosario: Zeus, p. 82.

Artículo 8.- Competencia en la colaboración y control judicial.
2. (...)
En los casos en los que el Estado peruano es la parte afectada con la medida cautelar, se exige como contracautela la presentación de una fianza bancaria y/o patrimonial solidaria, incondicionada y de realización automática en favor de la entidad pública afectada, por el tiempo que dure el proceso arbitral. El monto de la contracautela lo establece el/la juez/a o el tribunal arbitral ante quien se solicita la medida cautelar, dicho monto no debe ser menor a la garantía de fiel cumplimiento. La ejecución de la carta fianza se establece conforme a lo resuelto por el/la juez/a o el tribunal arbitral, según corresponda."

59. Por otro lado, debe tenerse presente que, en el ordenamiento jurídico peruano no se encuentra en cuestión la posibilidad de los árbitros de hacer uso del control difuso de la constitucionalidad de las leyes, poder - deber que el artículo 138 de la Constitución atribuye exclusivamente a los jueces para no aplicar al caso concreto la norma legal que resulte incompatible con la Constitución, puesto que la misma es una herramienta constitucional - propia de la concepción del Estado Constitucional de Derecho- conferida a los órganos y tribunales dotados de jurisdicción (teniendo como fundamento los principios de independencia y unidad de la función jurisdiccional), en la medida que la norma que se implique sea absolutamente pertinente y relevante para la eficacia de la decisión a tomar, y que suponga un perjuicio al derecho de una de las partes.

60. En ese sentido, el árbitro considera que la facultad que posee para aplicar el control difuso al amparo de lo establecido en el artículo 138 de la Constitución, ha sido reconocido en la Sentencia del Tribunal Constitucional en el Caso María Julia[26], y por

---

26 "*Siendo el arbitraje una jurisdicción independiente, como expresamente señala la Constitución, y debiendo toda jurisdicción poseer las garantías de todo órgano jurisdiccional (como las del Poder Judicial), es consecuencia necesaria de ello que la garantía del control difuso de constitucionalidad, prevista en el segundo párrafo del artículo 138º de la Constitución, pueda también ser ejercida por los árbitros en la jurisdicción arbitral, pues el artículo 138° no puede ser objeto de una interpretación constitucional restrictiva y literal, como exclusiva de la jurisdicción ordinaria o constitucional; "por el contrario, la susodicha disposición constitucional debe ser interpretada de conformidad con el principio de unidad de la Constitución, considerando el artículo 51.º (…), más aún si ella misma (artículo 38.°) impone a todos –y no solo al Poder Judicial– el deber de respetarla, cumplirla y defenderla" (STC 3741-2004-AA/TC, fundamento 9).*

(…)
No obstante, el ejercicio del control difuso de constitucionalidad en la jurisdicción arbitral debe ser objeto, como se acaba de expresar, de modulación por este Supremo Intérprete de la Constitución, con el propósito de que cumpla debidamente su finalidad de garantizar la primacía de la Constitución y evitar así cualquier desviación en el uso de este control constitucional. Por ello, se instituye la siguiente regla:

ende, su ejercicio es una competencia que le es propia, siempre que, como en el presente caso, se advierta que exista una norma que atente contra el debido proceso al establecer un tratamiento discriminatorio en favor de una de las partes e impidiendo a la parte que demanda tener acceso a una tutela efectiva, siendo esto último uno de los límites que establece el Tribunal Constitucional para la aplicación del control difuso..

61. En ese orden de ideas, y dadas las circunstancias anotadas precedentemente, en el presente caso, el árbitro considera que la contracautela establecida en el Decreto de Urgencia de manera indiscriminada y para toda solicitud cautelar, deviene en inaplicable por lo que, la contracautela que corresponde sea otorgada, se fijará de acuerdo al criterio establecido por el árbitro y por el plazo que dure la cautela de no innovar.

62. Se tomará como forma de cálculo de la contracautela el 10% del porcentaje de la obra principal pendiente de valorizar, para ello se tendrá en cuenta el porcentaje informado por el Contratista en su escrito presentado el 14 de julio de 2022. Se precisa sobre el particular que, no podemos tomar en consideración otro cálculo, debido a que la Entidad no cumplió con pronunciarse sobre la solicitud cautelar pese a encontrarse debidamente notificada.

63. En tal sentido, el Contratista a través del escrito de antecedentes **(ii)** informó que el porcentaje alcanzado al mes de Julio de 2021 fue el siguiente:

MES	VALORIZACION EJECUTADA ANTERIOR %
JULIO 2021. (01 AL 27)	89.93 %

El control difuso de la jurisdicción arbitral se rige por las disposiciones del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional y la jurisprudencia vinculante dictada por este Tribunal Constitucional sobre el control difuso. Sólo podrá ejercerse el control difuso de constitucionalidad sobre una norma aplicable al caso de la que dependa la validez del laudo arbitral, siempre que no sea posible obtener de ella una interpretación conforme a la Constitución y además, se verifique la existencia de un perjuicio claro y directo respecto al derecho de alguna de las partes."

64. De lo anterior, se verifica que el Contratista informó que la valorización alcanzada hasta Julio de 2021 representa el 89.93%, por lo que, el saldo pendiente de valorizar asciende al 10.07%. Dicho porcentaje, representa la suma de S/. 437,869.08 Soles del monto inicial del Contrato.

65. En ese sentido, el 10% del monto pendiente de valorizar asciende a la suma de S/. 43, 786.91 Soles, siendo este el monto que se fija como contracautela. Asimismo, se debe precisar que la custodia de la garantía se encontrará a cargo del Centro Arbitral, debiendo el Contratista presentar el original en mesa de partes del centro, dentro del horario establecido por el mismo

66. Asimismo, se precisa que la garantía solicitada debe tener una vigencia de 6 meses, y debe ser renovada antes de su vencimiento. En caso que la garantía venza o en caso no se renueve, esto implicará la caducidad de la media cautelar.

67. En consecuencia, este árbitro dispone y ordena al Consorcio que en un plazo de diez (10) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificado con la presente Decisión, cumpla con presentar ante el Centro, la carta fianza bancaria, incondicional y de realización automática, por el monto de S/ 43,786.91. Asimismo, se precisa que la garantía deberá ser emitida con la siguiente información ***"Por los daños y perjuicios que se pueda generar a la Municipalidad Distrital de Quiñota como consecuencia de la ejecución de la medida cautelar en el arbitraje entre el Consorcio León con la Municipalidad Distrital de Quiñota respecto del contrato N°90-2019-MDO"***

68. Teniendo en cuenta los fundamentos expuestos, el árbitro considera que corresponde declarar **FUNDADA** la medida cautelar solicitada por el Consorcio; sin perjuicio de que según sea el desarrollo de las actuaciones arbitrales aquél pueda ser modificado o revisado a petición de cualquiera de las partes ante el Tribunal Arbitral o Árbitro Único que se instale.

69. Finalmente, se disponer poner en conocimiento de la empresa *SECREX CESCE* la presente resolución, a fin de que proceda conforme corresponde.

Por tales consideraciones expuestas, el árbitro de emergencia **RESUELVE**:

PRIMERO: LEVANTAR el plazo de suspensión para emitir la decisión que resuelve el pedido cautelar.

SEGUNDO: Declarar **FUNDADA** la medida cautelar solicitada por el Consorcio León; y, en consecuencia, se ordena a la Municipalidad de Quiñota, abstenerse y/o suspender la realización los siguientes actos:

"Ejecutar bajo cualquier concepto, las siguientes cartas fianza, así como sus respectivas renovaciones, emitidas a favor de la Entidad en el marco del Contrato N°090-2019-MDQ, contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en los Sectores de Miraflores, Ututa, Trankapunco, Tutoroqo, Iquiyancha, Mamach'ucclla, Ccollapacc'aza, Lluscc'ojom Mamanchisniyoc y Janccayo en la Comunidad de Ccollana Distritp de Quiñota, Provincia de Chumbivilcas – Cusco" con código 345110, relativo a la Licitación Pública N° 003-2019-MDQ-1:

a) *CARTA FIANZA N° E1879-08-2020, emitida por SECREX CESCE, hasta por el monto de S/ 95,661.56 (Noventa y cinco mil seiscientos sesenta y uno con 56/100 soles) y sus respectivas renovaciones, por concepto de garantía de adelanto de materiales.*
b) *CARTA FIANZA N° E2740-07-2019, emitida por SECREX CESCE, hasta por el monto de S/ 434,825.30 (Cuatrocientos treinta y cuatro mil ochocientos veinticinco con 30/100 soles) y sus respectivas renovaciones, por concepto de garantía de fiel cumplimiento.*
c) *CARTA FIANZA N° E1760-03-2021, emitida por SECREX CESCE, hasta por el monto de S/ 29,085.55 (Veintinueve mil ochenta y cinco con 55/100 soles) y sus respectivas renovaciones, por concepto de garantía de fiel cumplimiento.*
d) *CARTA FIANZA N° E1759-03-2021, emitida por SECREX CESCE, hasta por el monto de S/ 35,921.18 (Treinta y cinco mil novecientos veintiuno con 18/100 soles) y sus respectivas renovaciones, por concepto de garantía de fiel cumplimiento."*

TERCERO: PRECISAR que el Consorcio León deberá continuar renovando las Cartas Fianzas descritas en el considerando primero.

CUARTO: DISPONER que, para la efectividad de la medida cautelar concedida, el Consorcio León debe presentar **en el plazo de diez (10) días hábiles**, contado a partir del día siguiente de notificado con la presente Resolución, cumpla con presentar una carta fianza bancaria, incondicional y de realización automática, en favor de la Municipalidad de Quiñota por el monto de S/ 43,786.91 (Cuarenta y tres mil setecientos ochenta y seis con 91/100 soles).

CUARTO: Sobre la garantía, **PRECISAR** lo siguiente:

1) La custodia se encontrará a cargo del Centro Arbitral, debiendo el Contratista presentar el original en mesa de partes del centro, dentro del horario establecido por el mismo.
2) La garantía debe tener una vigencia de 6 meses, y debe ser renovada antes de su vencimiento. En caso que la garantía venza o en caso no se renueve, esto implicará la caducidad de la media cautelar.
3) La garantía deberá ser emitida con la siguiente información ***"Por los daños y perjuicios que se pueda generar a la Municipalidad Distrital de Quiñota como***

consecuencia de la ejecución de la medida cautelar en el arbitraje entre el Consorcio León con la Municipalidad Distrital de Quiñota respecto del contrato N°90-2019-MDO"

QUINTO: DEJAR CONSTANCIA que la Municipalidad de Quiñota no absolvió el traslado conferido mediante Decisión N° 1.

SEXTO: PONER EN CONOCIMIENTO de la empresa *SECREX CESCE* la presente resolución, a fin de que proceda conforme corresponda.

Daniel Triveño Daza
Árbitro de Emergencia

CONSORCIO LEÓN vs. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIÑOTA.

DECISIÓN N° 8 – CUADERNO CAUTELAR

Lima, 14 de setiembre de 2022

ANTECEDENTE: El escrito presentado por el Consorcio León (en adelante, Consorcio) el 07 de setiembre de 2022, bajo la sumilla: *"Presento carta fianza."*

ANÁLISIS:

1. En el cuarto punto resolutivo de la Decisión N° 05 del 25 de julio de 2022, se dispuso para la efectividad de la medida cautelar concedida, el Consorcio, debía presentar una carta fianza incondicional y de realización automática a favor de la Municipalidad Distrital de Quiñota, por el monto de S/ 43,786.91 (Cuarenta y tres mil setecientos ochenta y seis con 91/100), otorgándosele para tal efecto el plazo de diez (10) días hábiles.

2. En esa línea, mediante escrito de fecha 10 de agosto del presente, el Consorcio solicito un plazo adicional de diez (10) días hábiles, para cumplir con presentar la carta fianza, habiéndosele otorgado dicho plazo mediante resolución N° 06 del 12 de agosto de 2022.

3. El día 26 de agosto de 2022, vencía el plazo concedido al Consorcio, por lo que mediante escrito de la misma fecha, éste solicito un plazo excepcional, argumentando que se estaba realizando el trámite para la emisión de la carta fianza, y que debido a la solicitud de ejecución de las cartas fianzas tenían problemas con las entidades bancarias; por lo que se resolvió mediante Decisión N° 07, otorgar por última vez el plazo de cinco (05) días hábiles, a fin que cumplan con presentar la carta fianza, bajo apercibimiento de levantar la medida cautelar de manera automática.

4. Finalmente, mediante escrito de visto, se verifica que el Consorcio presento la Carta Fianza requerida al Centro de Arbitraje y Resolución de disputas -CECARD, conforme a las precisiones efectuadas en el cuarto punto resolutivo de la Disposición N° 05, y en consecuencia, se debe tener por presentada la carta fianza con conocimiento de la Entidad. Asimismo, se precisa que el original de la Carta Fianza se encontrará en custodia de la Secretaría Arbitral.

DECISIÓN:

PRIMERO: **TÉNGASE POR CUMPLIDO** por EL CONSORCIO LEÓN, el mandato de la Disposición Cautelar N° 05, referido a la presentación de la contracautela en la modalidad de Carta Fianza a favor de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIÑOTA por el monto de

S/ 43,786.91 (Cuarenta y tres mil setecientos ochenta y seis con 91/100), por los daños y perjuicios que se pueda generar, como consecuencia de la ejecución de la medida cautelar.

SEGUNDO: **TÉNGASE POR PRESENTADA** la Carta Fianza por el CONSORCIO LEON a favor de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIÑOTA por el monto de S/ 43,786.91 (Cuarenta y tres mil setecientos ochenta y seis con 91/100), cuyo original se encontrará en custodia de la Secretaría Arbitral

TERCERO: **PONER EN CONOCIMIENTO** de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIÑOTA la presente resolución, para los fines pertinentes.

Daniel Triveño Daza
Árbitro de Emergencia